

次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、正しいものを2個選びなさい。

1. 甲は、人通りの多い路上で、不特定多数の通行人を勧誘して客を集めた上、近隣のビルの1室において、外部との出入りを制限した状態で、自らが雇用した男女に全裸で性行為を行わせ、それを6名の客に有料で観覧させて利益を得た。この場合、甲に公然わいせつ罪の共同正犯は成立しない。
2. 甲は、自己の所有するパソコンからわいせつな画像データをサーバーに送信して記憶・蔵置させた上、不特定多数の者が、インターネットを経由して同わいせつ画像データをダウンロードして、パソコンに記録・保存することを可能にした。そして、甲の顧客である不特定多数の者がわいせつな画像データファイルをダウンロードして顧客のパソコンに記録、保存した。この場合、記録・保存する者において、記録・保存の際、画像データのダウンロード等の作業をする必要があったとしても、甲にわいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。
(改)
3. 甲は、わいせつな映像が録画されたマスターDVDを所持していたが、甲には、同マスターDVD内に記録されたわいせつな映像を客の注文に応じて他のDVDに複写して販売する意図はあったものの、同マスターDVD自体を販売する意図はなかった。この場合、甲にわいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。(改)
4. 甲は、外国で販売する目的で、日本国内においてわいせつな写真を所持した。この場合、甲にわいせつ物有償頒布目的所持罪が成立する。(改)
5. 甲は、わいせつな映像が録画されたDVDを販売する目的で雑誌に広告を出し、申し込んできた複数の客から代金の振込みを受け、宅配便で配送する手続を採ったが、配送するトラックが途中で事故を起こしたため、同DVDは、客に届かなかった。この場合、甲にわいせつ物頒布等罪は成立しない。(改)

No.389

H23-15

わいせつの罪

正解

2、5（順不同）

正答率

39%

1 誤っている

最決昭 32.5.22、最決昭 31.3.6。「公然」とは、不特定又は多数の人が認識することのできる状態をいう（最決昭 32.5.22）ところ、判例は、不特定多数の人を勧誘した結果集まったそれぞれ数十名の客の面前でわいせつ行為をした事案に関し、当該わいせつ行為が「たとえ夜間一定の部屋を密閉してなされたとしても公然猥褻罪の成立を妨げるものではない」としている（最決昭 31.3.6）。本記述においては、甲は、不特定多数の通行人を勧誘して客を集めている以上、全裸で性行為を行うというわいせつ行為を、6名の客のみに、外部との出入りが制限された部屋で観覧させたにすぎないにしても、公然わいせつ罪の共同正犯が成立する。

2 正しい

まず、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪（175条1項後段）における「頒布」とは、「不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめること」をいう（最決平 26.11.25、百選Ⅱ101事件）。そして、同判例は、「不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて……わいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の『頒布』に当たる」とする。したがって、本記述の甲は、わいせつな画像データをサーバーに送信して記録・蔵置させた上、不特定多数の者がインターネットを経由してわいせつ画像データをダウンロードしてパソコンに記憶・保存することを可能し、顧客がわいせつ画像データをダウンロードしてパソコンに記憶・保存しているから、わいせつ電磁的記録等送信頒布罪が成立する。

3 誤っている

裁判例（富山地判平 2.4.13）は、ダビングテープのみを販売する意思でマスターテープを所持した場合も、わいせつ物有償頒布目的所持罪を構成するとしている。本記述では、甲は、他のDVDに複写して販売するという「有償で頒布する目的」をもって、わいせつな映像が記録されたマスターDVDを所持していることから、甲にわいせつ物有償頒布目的所持罪が成立する。

4 誤っている ★

最判昭 52.12.22。判例は、「有償で頒布する目的」とは「日本国内において販売する目的」としている。その理由として、判例は、175条の規定は、「わが国における健全な性風俗を保護するため、日本国内において猥褻の文書、図画などが頒布、販売され、又は公然と陳列されることを禁じようとする趣旨に出たもの」であるということを挙げている。本記述では、甲は、外国で販売する目的で、わいせつな写真を所持しているにすぎず、甲にわいせつ物有償頒布目的所持罪は成立しない。

5 正しい

175条1項前段。わいせつ物頒布等罪（175条1項前段）が成立するためには、わいせつ物を交付する約束が成立しただけでは足りず、わいせつ物が現実には交付されたことが必要であるとされている（大判昭 11.1.31、最判昭 34.3.5）。本記述では、甲は、わいせつな映像が録画されたDVDを宅配便で配送する手続を採ったが、配送事故により、同DVDは客に現実には交付されておらず、甲にわいせつ物頒布等罪は成立しない。